

1500278-09.2020.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos. (STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJ e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

2ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500278-09.2020.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500278-09.2020.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 871/20/201 - DEL.POL.APARECIDA, 2096298 - DEL.POL.POTIM, 871/20/201 - DEL.POL.POTIM

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CAIQUE MATHEUS DE LIMA BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu (sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia Caíque Matheus de Lima Barbosa, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 16 de abril de 2020, por volta das 23h10min, na Rua Luís Thomas de Lima, nº 510, Centro, Aparecida-SP, Caíque Matheus de Lima Barbosa comercializava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, as quais foram devidamente apreendidas.

Apurou-se que, durante o patrulhamento de rotina realizado no local supra citado, os policiais Priscila de Almeida Paiva e Leandro Quelemente Arantes Figueiredo, detiveram o Denunciado que, a princípio, tentou fugir e, encontraram em seu poder a quantia de R\$87,00 em espécie, 1(um) celular Motorola, 1 (uma) sacola plástica

contendo 51 microtubos eppendorf de cocaína (12,01g) e 39 pedras de crack (7,59g), além de 1 (um) celular preto da marca Samsung e 1 (um) rolo de papel alumínio parcialmente usado. O Denunciado confessou informalmente a mercancia ilícita. Interrogado, o réu permaneceu em silêncio.

Denúncia recebida em 06 de dezembro de 2021 (fl. 119).

Em resposta aos argumentos da Defensoria Pública (fls. 43/49), que requereu liberdade provisória ao Denunciado, sob o argumento da Pandemia do Covid - 19, o Ministério Público em fls. 38/42, não reconheceu o pedido, dada a quantidade de drogas encontrada junto ao Denunciado, além de esclarecer que, para que o réu seja beneficiado com a liberdade provisória devido às circunstâncias do Covid-19, necessário se faz a comprovação de que o sistema prisional colocará em risco a saúde do réu já prejudicada, ou seja, é necessário que o réu, tendo um grave problema de saúde, comprove que o sistema prisional não irá atendê-lo de forma adequada. Situação que, segundo o Ministério Público, não se encaixa à realidade do réu, sendo que ainda requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva .

Decisão de fls. 50/52, concedeu ao réu o benefício da liberdade provisória, conforme requerido pela Defensoria Pública, levando em consideração decisões dos Tribunais Superiores, com a observação, entretanto, de que o réu deveria se comprometer a comparecer bimestralmente em Juízo, informando sobre qualquer alteração de endereço.

Em Defesa Prévia, o réu argumentou que os fatos a ele imputados não são verdadeiros, uma vez que nada foi encontrado em seu poder , de modo que não há sequer indícios suficientes para embasar a autoria do delito que lhe é imputado. Argumenta ainda que é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa. Logo, se recebida a denúncia, a melhor adequação típica seria correspondente ao parágrafo 4º do artigo 33 e não o do caput. Em resposta, a Decisão de fls. 119/120, recebeu a denúncia, alegando que a matéria alegada pela Defesa não configura caso de absolvição sumária do réu. Em audiência de instrução, debates e julgamentos realizada em 12/04/2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A defesa se manifestou sustentando, de forma preliminar, a nulidade da obtenção da prova, em razão do ingresso em domicílio sem autorização judicial. No mérito, sustentou não teriam sido provados a praticado pelo acusado de nenhum ato de mercancia, pedindo a aplicação da pena no menor patamar legal. Pediu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a figura privilegiada do tráfico de entorpecente, aplicando-se a redutora no maior patamar.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

PRELIMINARMENTE

DO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO

Cumprе salientar que, a despeito das alegações do acusado de que os policiais teriam ingressado em sua residência sem autorização e sem mandado judicial, tal ingresso é válido e regular.

Vejamос.

O artigo 5º, XI, da Constituição de 1988, traz a proteção ao domicílio, tornando-o inviolável. Por domicílio, entende-se o espaço físico no qual o indivíduo goza de sua privacidade, nas suas mais variadas modalidades. Assim, o domicílio deverá ser entendido como qualquer compartimento habitado utilizada para moradia, profissão ou atividade. Por isso, escritórios, consultórios devem ser enquadrados no conceito de domicílio.

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Portanto, durante o dia, é possível o ingresso em domicílio nas seguintes hipóteses: com o consentimento do morador, em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou mediante determinação judicial. Durante a noite, o ingresso em domicílio alheio só pode ocorrer nos seguintes casos: com o consentimento do morador, flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. No caso dos autos, os dois policiais militares, pelo tempo transcorrido entre o flagrante, não se recordaram dos fatos, não podendo corroborar o por eles dito em solo policial de que o acusado teria se evadido para o interior da residência no momento da chegada dos policiais.

Todavia, há outros diversos elementos de prova nos autos que dão sustentação à legitimidade do ingresso em seu domicílio.

Como acima transcrito, uma das hipóteses em que é permitido o ingresso em domicílio alheio são nas situações de flagrante delito. Ora, dos autos consta, inclusive fato esse confessado pelo próprio acusado, que em sua residência foram encontradas as substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 10/11).

O crime de tráfico de drogas é peculiar, pois algumas de suas condutas correspondem a crimes permanentes, cuja consumação se prolonga no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento.

Dessa forma, quem, por exemplo, guarda ou tem em depósito determinada quantidade de droga em sua residência está continuamente em flagrante delito.

Considerando a exceção trazida pelo próprio dispositivo constitucional a respeito da inviolabilidade do domicílio, conclui-se que o armazenamento de drogas em determinada residência admite a entrada de agentes policiais independentemente de autorização judicial.

No caso dos autos, haviam fundadas suspeitas de que no interior da residência do acusado estaria ocorrendo o flagrante delito, tendo em vista que os milicianos teriam recebido denúncias de que naquele local estaria ocorrendo a prática de entorpecentes, além do fato do acusado ter tentado se evadir no momento em que avistou os policiais.

Dessa forma, observo, portanto, que a conduta está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal, formalizada no julgamento do RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual se firmou entendimento no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

Este é, inclusive, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

"Habeas corpus" - Tráfico de drogas - Alegação de que as provas foram obtidas ilicitamente, mediante violação de domicílio - Pedido de concessão de ordem para trancar a ação penal e nulificar o feito, com a consequente soltura do paciente - Não acolhimento - Ausência de constrangimento ilegal - Inteligência do art. 5º, XI, da CF, que dispensa consentimento do morador e ordem judicial para o ingresso em domicílio alheio nos casos de "flagrante delito" - Tráfico de drogas nas modalidades "guardar" e "ter em depósito" - Crime permanente - Possível a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP) - Existência de fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais na residência do paciente - Precedentes - Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2057567-23.2021.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 08/04/2021; Data de Registro: 08/04/2021)

Assim posto, resta afastada qualquer nulidade da obtenção da prova.

No mérito, a ação penal é PROCEDENTE, com efeito, analisando atentamente o acervo probatório, e considerando os elementos indiciários existentes nos autos, verifica-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, devendo ser o acusado condenado no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. . Nestes termos, do percuente exame do acervo probatório, infere-se que restaram satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva. A materialidade delitiva resultou provada pela: Denúncia (fl. 01), Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02), Termo de Depoimento de Leandro Quelemente Arantes

Figueiredo (fls. 03), Termo de Depoimento de Priscila de Almeida Paiva (fls. 04), Termo de interrogatório (fl. 05), Nota de Culpa (fl. 06), Boletim de Ocorrência alusivo aos fatos (fls. 07/09), Auto de Exibição / Apreensão (fls. 10/11), Requisição IML - PESSOA (fl. 22), Requisição IC - Entorpecente (fl.17), Informações sobre a Vida Pregressa (fl. 25), Relatório Final oferecido pelo Delegado de Polícia (fls. 81/82), Certidão e Folha de Antecedentes (fls. 31/33, 99/102 e 111/114), Laudo Pericial e Laudo IML - pessoa (fls. 125/128), Laudo IC - Objeto (fls. 77/79). A autoria resta igualmente demonstrado, especialmente pela ampla prova oral produzida em audiência, que definem, sem qualquer sombra de dúvida, a autoria delitiva do réu.

Passo a análise da prova oral produzida.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Leandro Quelemente Arantes Figueiredo disse em juízo que: (relato livre)

Não se recorda tanto dos fatos. Se lembra que estavam em patrulhamento de rotina pela cidade junto com o SGP, em duas viaturas. Fizeram a abordagem no indiciado, localizando com ele as drogas e o dinheiro. Não se recorda de mais detalhes do caso, pois foram muitas ocorrências desde o acontecido.

Em resposta às indagações feitas pelo Ministério Público, respondeu que geralmente as apreensões feitas no Potim, são feitas através de denúncias de populares, seja pelo 190 ou diretamente. Não se lembra da ocorrência especificamente. Apenas o rosto do acusado. Mas se recorda de com ele ter sido encontrada as drogas. Recordase dele ter dito que estava vendendo entorpecentes para recuperar sua motocicleta que estava apreendido no depósito.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Priscila de Almeida Paiva disse em juízo que: (relato livre)

Aconteceu em Potim. Estavam em patrulhamento junto com o comando, SGHP3. Abordaram o indivíduo e com ele encontraram os entorpecentes e o dinheiro. Se lembra de muito pouco da ocorrência, pelo tempo passado.

As denúncias recebidas são tanto pelo 190 quanto pelos populares que passam notícias para a viatura. Nesse caso, houve a noticia de venda de droga no local. Chegando ao local, abordaram o denunciado e com ele encontraram entorpecentes e dinheiro. Não se recorda dele ter dito algo a respeito da droga.

Interrogado, o réu Caíque Matheus de Lima Barbosa alegou em juízo que:

Os fatos são verdadeiros. As drogas eram dele. Estava desempregado. Estava trabalhando de motoboy. A moto tinha estragado. Não tinha dinheiro pagar o conserto da moto. Precisava consertar a moto para trabalhar. Pegou a droga para vender e fazer dinheiro para o conserto de sua moto. Não tinha começado a vender. Ele foi abordado na porta de sua casa, estava lavando algumas moto, para ganhar algum dinheiro. Não chegou a correr, pois foi abordado na porta de sua casa. Ele ficou sentado na calçada, e os policiais entraram em sua residência e acharam as drogas. Ele morava na residência. As drogas foram encontradas na sua casa. As drogas eram suas e tinha comprado para vender e fazer um dinheiro rápido.

Nota-se que ambas as testemunhas prestaram firme depoimento vinculando à acusada às drogas apreendidas.

Aos depoimentos policiais também deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição.

Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014). E conforme esta Egrégia Corte: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia

com o restante da prova". (TJSP Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. SouzaNery, j. 27/08/2015).

Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice.

Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos.

E no caso, as testemunhas policiais ouvidas em juízo asseveraram que, após receberam denúncias de tráfico sendo praticado naquele local, avistaram o acusado e o detiveram em poder das substâncias entorpecentes devidamente apreendidas (fls. 10/11) e periciadas (fls. 77/79).

No mais, quando ouvido em juízo, o réu confessou a prática do delito.

Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122).

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova.

Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incommum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.

(Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003)." (AC2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

De acordo com a Doutrina: "É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, págs. 378/379).

Tem-se que a confissão não é elemento isolado nos autos, uma vez que foi corroborada pelo restante do conjunto probatório. Neste sentido: "A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288).

É dizer: a confissão tem valia, ainda mais porquanto corroborada pelo restante da prova produzida, sendo apta a fundamentar a prolação de decreto condenatório, não havendo nos autos a comprovação da existência de nenhum vício de vontade que pudesse determinar a sua desconsideração.

Quanto ao tráfico de drogas, analisados os aspectos referidos, que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, é evidente que a droga encontrada no caso em questão destinava-se a mercancia ilícita, mormente pelas circunstâncias em que ocorreu o flagrante, bem como pela forma e local onde foram encontrados os entorpecentes, o que afastam

qualquer tese de ser mero usuário de entorpecentes.

Cabe citar que a venda propriamente dita da droga não é elemento indispensável para a configuração da traficância, tendo em vista consistir o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) em tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração do aludido delito, a prática de qualquer uma das 18 ações tipificadas (importar, exportar, remeter preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), dispensada a prova do ato da mercancia em si, perfilhando desse mesmo entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos. (STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJ e 01/07/2016)

TÓXICO Crime de tráfico Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito Depoimentos de agentes policiais Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas Análise que se faz em cada caso concreto Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório Policial que se diz usuário Flagrante legal Tipo penal misto alternativo que dispensa a prova da conduta da venda para a prisão e acusação Condenação mantida Pena correta e adequada ao caso Regime fechado mantido Recurso improvido (TJSP, Relator (a): Newton Neves; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2015; Data de registro: 01/04/2015).

Certo é que, além da harmônica prova oral acusatória, a espécie da substância entorpecente apreendida, a forma como acondicionada, as circunstâncias do flagrante, tornam evidente que a droga destinava-se ao consumo de terceiros. Tais circunstâncias constituem elementos relevantes para a configuração do crime tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Em suma, todos os elementos de convicção compilados nos autos efetivamente indicam que a droga apreendida destinava-se ao tráfico.

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que a acusada era sabedora e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que a acusada, de forma deliberada, estava na posse de substâncias entorpecentes descritas no laudo químico-toxicológico de fls. 77/79, sem a devida autorização, não restando qualquer dúvida a respeito do caráter consciente da conduta.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Dessa forma, mister se faz a condenação da acusada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase ainda, assinalo que o réu é tecnicamente primário e não portador de antecedentes criminais. Merece valoração negativa a natureza das substâncias entorpecentes encontradas, uma vez que com o acusado, além da variedade, foi encontrada grande quantidade de cocaína sob a forma de crack, que, com é cediço, possui altíssimo potencial de vício e que causa nefastos problemas sociais, tendo, então, potencial devastador sobre os consumidores e, conseqüentemente, toda a sociedade. As demais circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, bem como do art. 42, da lei 11.343/06 são normais à espécie de delito. Assim, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias

multa pelo delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez que o custodiado confessou os fatos que lhe foram imputados na denúncia. Dessa forma, atenuo a pena intermediária para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa pelo delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343. Na terceira fase, a prova dos autos não é suficiente para comprovar o envolvimento do acusado com organização criminosa, nem para concluir, seguramente, que ele se dedica à prática reiterada do tráfico ilícito de drogas ou outros crimes.

No caso dos autos, a despeito do denunciado ostentar condenação definitiva (autos 1500839-33.2020.8.26.0621), esta se deu por fato posterior ao que está aqui em análise. Dessa forma, segundo entendimento que se consolidou nos tribunais superiores, não pode ser considerada para fins de reincidência, mas antecedentes ou mesmo para afastar a minorante do tráfico em sua forma privilegiado (art. 33, §4º, da lei 11.343/06).

É certo que a Nova Lei de Drogas aperfeiçoou a sanção penal ao operar a distinção entre meros mercadores ocasionais, também merecedores de atenção do Estado, dos comerciantes de droga mais estruturados, verdadeiros empresários do tráfico.

Distinção reclamada há muito tempo pelos aplicadores do Direito, tem por consequência a menor reprovabilidade da conduta do traficante ocasional e sua pena encontra fundamento e limite com a redução a integrar o tipo penal para os que apresentem as condições subjetivas típicas daqueles que não tenham estruturado envolvimento com o tráfico de drogas.

No presente caso, entendo cabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e, em razão da variedade e da natureza da droga encontrada, entendo por bem assim reduzir as penas no patamar de 1/2, diminuindo-as para 2 (dois) ano e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso, suficientes para a reprovação do tráfico de drogas. Ausentes outras circunstâncias que alterem as penas, torno-as definitivas nestes patamares.

Tendo em vista a decisão do C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, que retirou o caráter de hediondez do tráfico privilegiado e afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado, o regime inicial de cumprimento de pena do investigado será o aberto em razão da quantidade da pena aplicada e atento aos critérios dos artigos 33, combinado com o artigo 59, ambos do Código Penal. No mesmo sentido, decidiu a C. Segunda Turma do STF: "Tráfico de entorpecentes: fixação do regime e substituição da pena. Não sendo o paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59), a gravidade em abstrato do crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, não constitui motivação idônea para justificar a fixação do regime mais gravoso. Com esse entendimento, a Segunda Turma, após superar o óbice do Enunciado 691 da Súmula do STF, concedeu "habeas corpus" de ofício para garantir ao paciente, condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão pela prática do delito de tráfico de drogas, a substituição da reprimenda por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais, bem assim a fixação do regime inicial aberto. O Colegiado entendeu que o paciente atende aos requisitos do art. 44 do CP, razão pela qual o juízo deve considerá-los ao estabelecer a reprimenda, de acordo com o princípio constitucional da individualização da pena. (HC 133028/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 12.4.2016. (HC-133028).

Por isso, diante desses argumentos, entendo suficiente para a justa reprimenda a fixação de regime inicial prisional aberto.

Estão presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade imposta ao réu por duas penas restritivas de direitos, mais especificadamente pela prestação pecuniária no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser paga à entidade pública ou privada de destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução penal e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por igual prazo da pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada, autorizada a redução desse prazo, nos moldes do art. 46, § 4º, do Código Penal.

Em caso de descumprimento o regime inicial para o cumprimento de pena será o

aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu CAIQUE MATHEUS DE LIMA BARBOSA, qualificado nos autos, às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicado o redutor legal previsto no §4º do referido artigo. Ainda, fica a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, na forma acima estipulada.

O sentenciado respondeu em liberdade e poderá recorrer em liberdade, salvo se preso por outro motivo.

Decreto ainda o perdimento da quantia em dinheiro apreendida em favor do FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Condeno o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão.

Após o trânsito em julgado:

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06;

Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Aparecida, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA